

次の【事例】に引き続く事情に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、甲に殺人未遂罪の中止犯が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、殺意をもって、乙の頭部目掛けて包丁で1回切り付けたが、乙は、これを左腕で防いだため、左前腕部切創の傷害を負った。

【記述】

ア. 乙の負った傷害は、全治約2週間の左前腕部切創にとどまり、生命に危険のある状態には至らなかった。甲は、更に乙に切り付けようとしたが、通行人が近づいてくるのを認めて、自己の犯行が発覚すると思い、その場から逃走した。

イ. 乙は、前記左前腕部切創に起因する出血のため、早期に治療を受けなければ出血性ショックにより死亡する危険のある状態となった。甲は、乙に致命傷を与えたと思い、その場を立ち去ろうとしたが、乙から「助けてくれ。」と懇願されたため、憐憫の情を催し、通行人に「あそこに怪我人がいるから、あとはよろしく。」とだけ告げて立ち去った。乙は、その通行人が手配した救急車によって病院に搬送されて治療を受けた結果、死亡するに至らなかった。

ウ. 乙の負った傷害は、全治約2週間の左前腕部切創にとどまり、生命に危険のある状態には至らなかった。しかし、甲は、乙に致命傷を与えたものと信じ込み、その場を立ち去った。

エ. 乙の負った傷害は、全治約2週間の左前腕部切創にとどまり、生命に危険のある状態には至らなかった。甲は、更に乙に切り付けようとしたが、乙から「助けてくれ。」と懇願されたため、憐憫の情を催し、そのままその場から立ち去った。

オ. 乙は、前記左前腕部切創に起因する出血のため、早期に治療を受けなければ出血性ショックにより死亡する危険のある状態となった。甲は、更に乙に切り付けようとしたが、乙から「助けてくれ。」と懇願されたため、憐憫の情を催し、乙を病院に搬送して治療を受けさせたが、乙は治療の甲斐なく出血性ショックにより死亡した。

No137

H24-11

中止犯

正解

ア 2 イ 2 ウ 2 エ 1 オ 2

正答率

70%

ア 成立しない

最決昭 32.9.10。本記述では、甲が通行人が近づいてくるのを認めて、自己の犯行が発覚すると思い、更に包丁で切り付けるのを止めていることが、「自己の意思により」犯罪を中止した（43条ただし書）といえるかが問題となる。判例は、被告人が無理心中の目的で母親をバットで殴打し、頭から血を流して苦しんでいる母親を見て恐怖驚愕し、その後の殺害行為を実行しなかった事案につき、被告人の犯行完成の意力を抑圧した事情原因が、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障害に基づくと認められる場合は、いわゆる中止未遂ではなく、障害未遂に当たると解している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者本人が外部的障害を認識した結果、行為者本人及び一般人の立場からみて「やろうと思ってもできない」と判断できる場合には、任意性を認めるべきではないことを挙げている。よって、甲が通行人が近づいてくるのを認めて、自己の犯行が発覚するとして殺害行為を止めたことは、犯行の完成を妨害するに足る性質の障害に基づくと認められ、「自己の意思により」犯罪を中止したとはいえない。したがって、本記述の事案では、中止犯は成立しない。

イ 成立しない

大判昭 12.6.25。本記述では、甲が通行人に「あそこに怪我人がいるから、あとはよろしく。」とだけ告げて立ち去っていることが、「犯罪を中止した」（43条ただし書）に当たるかが問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、43条ただし書の中止犯は、犯人が犯罪の実行に着手した後、その継続中に任意に実行を中止し、若しくは結果の発生を防止することにより成立するものであり、結果発生の防止は必ずしも犯人が単独で行わなければならないものではないが、少なくとも犯人自身が結果発生の防止を行ったのと同視するに足るべき程度の努力を行うことを必要としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、結果防止努力について、自ら独力で結果を防止した場合のみに限定する必要はないが、結果防止に対する真摯な努力がみられない場合には、責任減少は認められないし、政策的にも、一定の結果防止努力を要件とすることは合理的であることを挙げている。本記述では、甲の行為は、通行人に「あそこに怪我人がいるから、あとはよろしく。」とだけ告げて立ち去っており、乙が早期に治療を受けなければ出血性ショックにより死亡する危険のある状態であることに照らすと、犯人自身が結果発生の防止を行ったのと同視するに足るべき程度の努力を行ったとはいえず、「犯罪を中止した」に当たらない。したがって、本記述の事案では、中止犯は成立しない。なお、甲は、乙から「助けてくれ。」と懇願され、憐憫の情を催しているため、「自己の意思により」の要件は認められる。

ウ 成立しない

本記述では、甲が乙に致命傷を与えたものと信じ込み、更に包丁で切り付けるのを止めているため、「自己の意思により」（43条ただし書）に当たるかが問題となる。上述の通り、任意性に関しては、行為者本人及び一般人の立場からみて「やろうと思ってもできない」かを基準とし、物理的な障害が存在する場合はもちろんのこと、外部的障害がないのにあると誤信して中止した場合にも任意性を認めることはできないとされている。よって、甲の行為は、致命傷を与えたものと信じ込んでいるため、やろうと思ってもできなかったといえ、「自己の意思により」に当たらない。したがって、本記述の事案では、中止犯は成立しない。なお、甲の実行行為は、乙の生命を危険な状態にするのに至らないものであり、更なる殺害行為を止めてその場を立ち去っているため、「犯罪を中止した」の要件は認められる。

エ 成立する

東京高判昭62.7.16(百選I70事件)。本記述では、甲が包丁で乙を切り付ける行為を止めて、そのままその場から立ち去っており、「犯罪を中止した」(43条ただし書)に当たるかが問題となる。裁判例は、本記述と類似の着手未遂すなわち実行行為が終了していない段階で中止犯の成否が問題となった事案において、「着手未遂の事案にあつては、犯人がそれ以上の実行行為をせずに犯行を中止し、かつ、その中止が犯人の任意で出たと認められる場合には、中止未遂が成立することになる」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、中止犯を認めるためには、犯罪の完成を妨げる行為すなわち中止行為によって結果が発生に至ったことを必要とし、実行行為が行われたが未だ結果発生に向かって因果の経過が進行を開始していない場合には、それ以後の実行行為を中止すれば中止行為としては十分であることを挙げている。よって、乙の生命に危険のある状態には至っていないという着手未遂の場合において、甲がそれ以上の実行行為を行わず立ち去ったことは、「犯罪を中止した」に当たる。したがって、本記述の事案では、中止犯が成立する。なお、甲は、乙から「助けてくれ。」と懇願され、憐憫の情を催しており、「自己の意思により」の要件も認められる。

オ 成立しない

本記述では、甲が乙に懇願され、憐憫の情を催し、乙を病院に搬送して治療を受けさせたが、治療の甲斐なく出血性ショックにより死亡しているため、結果が発生した場合に、中止犯が成立するかが問題となる。中止犯の成立に関しては、条文が明確に未遂に限定している以上、既遂になった場合まで中止の効果を認めることは無理であるとされている。よって、乙の死亡という結果が生じ既遂となった以上、中止の効果を認めることはできない。したがって、本記述の事案では、中止犯は成立しない。